

1501275-85.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501275-85.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501275-85.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

LUIS CARLOS DA SILVA, qualificado no autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque em 16 de maio de 2022, por volta das 16h, na Rua Antonia Manuel dos Santos, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade e Comarca de Arujá, o acusado, agindo em unidade de desígnios e em concurso com duas outras pessoas não identificadas, trazia consigo, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína em forma de crack, 02 (duas) porções de cocaína, e 18 (dezoito) porções de maconha, entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a exordial acusatória o acusado, em concurso com os demais agentes não identificados, trazia consigo e oferecia a venda os entorpecentes. Ocorre que os guardas civis municipais receberam informação de que naquele local estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. À luz da informação foram verificar a veracidade e ao chegarem ao local se depararam com o acusado em companhia de outras duas pessoas.

Eles, então, ao visualizarem a viatura, imediatamente tentaram se evadir, dispensando de imediato uma bolsa que - posteriormente recuperada - continha os entorpecentes mencionados.

Após curta perseguição, os guardas municipais lograram êxito em abordar o acusado, que admitiu o tráfico de entorpecentes, sendo consigo encontrada a quantia de R\$

90,00 em notas trocadas (fls. 59/62).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 29/32). Auto de exibição e apreensão (fls. 08/09). Laudo de exame toxicológico (fls. 13/18 e 67/75). Folha de antecedentes (fls. 33/36).

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 39/41).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 107/109).

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2022 (fls. 119/120).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado ao final (fls. 172/175).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Pontuou que nenhuma circunstância há a demonstrar a situação narrada pelo réu de que teria sido forjado o flagrante.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase afirmou que as circunstâncias são desfavoráveis diante do concurso de pessoas e variedade das drogas, além dos maus antecedentes. Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa do artigo 65, inciso I do Código Penal. Na terceira fase não faz jus o réu a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Requereu a fixação de regime inicial semiaberto, não sendo cabível a substituição da pena restritiva de direitos ou sursis.

A defesa do réu, em alegações finais orais, esclareceu que o réu é primário e de bons antecedentes. Discorreu que a narrativa da acusação é a mesma trazida na maioria das acusações de tráfico de drogas da Comarca. Externou que os guardas municipais teriam corrido atrás dos suspeitos e lograram capturar um deles.

Argumentou que ausente de justa causa, para validar o desvio, os guardas encaparam a narrativa da denúncia anônima e da confissão informal. Afirmou que um dos guardas afirmou não saber qual dos indivíduos teria jogado a sacola de drogas e nem mesmo se houve a alegada confissão. Pleiteou a absolvição diante da fragilidade probatória. Alternativamente, em caso de condenação, observou que as circunstâncias judiciais são favoráveis, e requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Complementou que deve ser imposto o regime inicial aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Vieram-me conclusos os autos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade do delito de tráfico não está devidamente comprovada, uma vez que houve atuação ilegal da Guarda Civil Metropolitana, o que acarreta a ilicitude de toda a prova colhida nos autos.

A autoria delitiva também não restou satisfatoriamente comprovada.

Passo à análise da prova oral colhida.

A testemunha André, Guarda Civil Municipal, relatou que no dia da ocorrência, em patrulhamento próximo ao local, receberam denúncia de um munícipe, e se deslocaram até o local da denúncia, chegando lá três indivíduos se evadiram do local onde conseguiram abordar Luis Carlos a umas três quadras. Pontuou que um dos indivíduos deixou cair uma bolsa rosa e um boné deixado com dinheiro. Externou que ao abordá-lo o mesmo confessou que estava na prática do tráfico, assim o conduziram até a Delegacia de Polícia onde foi feito o boletim de ocorrência. Destacou que segundo informado pelo réu que ele se evadiu do local com medo de ser pego novamente, tendo ele disse que foi dito pela Juíza à época que iria colocá-lo na cadeia por oito anos. Observou que não recorda as palavras certas do acusado, porque tem muita ocorrência, mas a confissão ocorreu na hora da abordagem. Admitiu que um dos três indivíduos soltou a sacola, mas não viram quem foi.

A testemunha Fernando, Guarda Civil Municipal, relatou que estava com seu companheiro Almeida patrulhando o Parque Rodrigo Barreto, quando um munícipe parou a viatura e informou que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na referida

rua. Disse que após alguns metros três indivíduos avistaram a viatura, saíram em desabalada carreira, jogaram uma bolsa rosa e deixaram cair boné e chinelo. Aduziu que umas três quadras acima lograram êxito em abordar o Luis Carlos, de pronto ele foi identificado e confessou para a equipe que estava praticando o tráfico de entorpecentes. Informou que pegaram a bolsa que continha os entorpecentes dentro e conduziram o acusado para a Delegacia de Polícia.

O réu disse que tem 21 anos, trabalha como tatuador, ganha dois mil reais, estudou até o primeiro ano, não é casado e não tem filhos, já foi processado por tráfico de drogas. Declarou que estava indo até a casa da sua namorada, que fica bem próxima da rua da biqueira, que é a Rua Quarenta e Oito. Afirmou que passaram dois moleques correndo e entraram dentro da viela, na sequência já passaram os dois Rocam. Acrescentou que como não devia nada continuou andando e seguiu caminho, quando veio a viatura e os policiais o enquadraram. Complementou que os policiais fizeram perguntas até que bateu no rádio deles que não conseguiram alcançar os outros, nessa eles disseram que teriam que apresentá-lo na delegacia referente ao outro BO pelo fato de não estar assinando. Disse que respondeu que iria de boa então, já que era só para se apresentar na delegacia, eles perguntaram se não ia precisar algemar e se iria dar trabalho respondendo que não. Comentou que o colocaram na viatura e levaram para dentro da biqueira onde realmente tem um ponto de droga e apresentaram uma bolsa falando que era sua e que teria que segurar porque não haviam achado os outros.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O laudo toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas encontradas.

Os guardas civis metropolitanos contaram como ocorreu a abordagem do acusado, verificando-se contudo, diversas lacunas em seus depoimentos.

Consoante relatado os guardas municipais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia de munícipe dando conta da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Dirigiram-se ao local, quando avistaram três indivíduos que empreenderam fuga, visualizando que foi atirada uma sacola e um boné. Lograram êxito em capturar o acusado que, supostamente, teria confessado informalmente a prática delitiva.

Em solo policial o réu permaneceu silente. Já em Juízo o acusado negou o cometimento do delito, afirmando que se dirigia até a casa de sua namorada, quando passaram por ele dois indivíduos e na sequência foi abordado pelos oficiais da Rocam. Complementou que como os demais indivíduos não foram encontrados os policiais foram até um ponto de drogas e pegaram uma sacola, dizendo ao acusado que lhe seria atribuída a responsabilidade pelos entorpecentes.

Primeiramente, aponta-se que no caso dos autos, defronta-se este juízo com a atuação ilegal, já que fora das atribuições legais e constitucionais da Guarda Civil Metropolitana, o que acarreta que toda a prova é derivada de atuação ilegal da Guarda Civil Metropolitana de Arujá.

Observo que a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve à superação do postulado da presunção de inocência e permita a imposição legítima de uma sanção penal. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito às regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas.

Assim, não é possível, dentro de um processo penal de fundamento democrático, a valoração da prova dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual.

Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte legal da prova.

Nesse sentido:

“assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não

é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: TirantloBlanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente.

Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais e de regras legais.

O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

Por outro lado, as provas, ilícitas por origem e derivação, não são capazes de afastar a presunção constitucional de inocência.

Assim, excluindo toda a atuação ilegal da Guarda Civil, não remanesce qualquer outra prova que pudesse amparar um juízo de mérito de procedência.

Extrai-se dos autos que a prova produzida em juízo tem uma fonte: diligência de polícia preventiva realizada pela Guarda Civil.

O art. 144, parágrafo 8º da CF/88 dispõe que “os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.

O Município de Arujá, atendendo ao comando constitucional, constituiu, de fato, a Guarda Civil visando a preservação de seus bens, serviços e instalações. Trata-se, assim, de verdadeira guarda patrimonial.

A mesma Constituição, por sua vez, no art. 144, parágrafo 5º, asseverou que cabe às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

Portanto, por uma simples leitura dos dispositivos verifica-se que não cabe à Guarda Civil a atividade fim de polícia preventiva, como, no caso em tela, de abordagem de sujeitos suspeitos da prática de infração penal.

Em outras palavras, a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, somente pode ser realizada e considerar-se, destarte, legal cumprindo-se dois pressupostos: a) que haja fundada suspeita de ocultação de objetos ilícitos; b) que a autoridade tenha competência legal para fazê-lo.

A estes servidores da municipalidade, frise-se, não são acometidas as funções de polícia judiciária ou repressiva e, assim, não estão legitimados a coletarem provas voltadas às futuras utilizações em processo penal ou a realizarem prisões nas quais não haja clara evidência de flagrante, em ambas situações com violação direitos fundamentais.

Nesse sentido, acerca da ausência de competência legal da guarda civil para atividade de polícia e, portanto, da ilicitude da prova é o posicionamento atual da 6ª Turma do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a

rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal. 3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros. 4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. 5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. 8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como

regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. 12. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1977119 - SP (2021/0391446-0) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 6ª turma - 16.08.2022).

Segundo o E.TJSP, no mesmo sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda civil não tem competência constitucional para exercício de atividade policial e, portanto, não pode por seu livre arbítrio abordar e revistar pessoas que não estejam em situação visual, crepitante e concreto de flagrante delito. Se o fizer, a prova assim produzida e toda aquela daí decorrente será ilícita, contaminando a validade da investigação daí decorrente. (TJSP - Apelação Criminal nº 1501278-74.2020.8.26.0320 - Rel. Sérgio Mazina Martins - Limeira - j. 23 de julho de 2021).

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração que espera o trancamento da ação penal com base na nulidade da prova. Busca e apreensão realizada por Guardas Municipais. Ausência de justa causa. Ordem concedida. (TJSP - Habeas Corpus n. 2016545-19.2020.8.26.0000 - 16ª Câmara - Rel. Otávio de Almeida Toledo - 04.08.2020).

No caso dos autos, tem-se ainda que não há nos autos razão fático-jurídica para a prisão do acusado, pela guarda civil.

Anote-se que a versão dos guardas civis contém diversas lacunas, tendo afirmado que receberam denúncia de munícipe não identificado sobre a prática do comércio espúrio e que um dos três indivíduos que estavam no local deixou cair uma bolsa rosa e um boné contendo dinheiro, não visualizando qual desses três indivíduos portava a sacola.

Com efeito, no caso sub judice, efetivamente de relevante existe apenas o alegado encontro de entorpecentes pelos guardas civis metropolitanos e o depoimento destes no sentido de que o réu efetivamente realizava tráfico de drogas.

O réu rechaçou que trazia drogas consigo, como dito, relatando que a responsabilidade pelas drogas lhe foi atribuída em razão da não localização dos

outros dois indivíduos que eram perseguidos pelos guardas e se evadiram da abordagem.

Assim, pela prova oral colhida nos autos, não há certeza de que o réu possuía drogas para fins de tráfico.

Cabe observar que o réu negou o tráfico de drogas com veemência em juízo e os guardas civis metropolitanos não informaram terem visto o réu praticando efetivamente tráfico de drogas.

O fato de o acusado sair correndo é controverso e de todo modo, não é incomum que determinados indivíduos, especialmente em bairros populares, tenham certo receio de abordagens policiais ou de guardas, e procurem se esquivar destas abordagens, sem que isso represente necessário e seguro indicativo de que tenham cometido o crime imputado. Não seria, por exemplo, uma atitude inesperada por parte de um usuário de drogas, que está em vias de adquirir entorpecente, ou mesmo de indivíduo que já registrou passagem, como o acusado.

Ainda, não há notícia de realização de campana que pudesse permitir o acompanhamento de ações que indicassem efetiva prática de comércio de drogas pelo acusado.

Ressalto que inexiste qualquer perícia grafotécnica nos eppendorfs e trouxinhas de maconha, que aponte que efetivamente esta droga pertencia ao acusado, não havendo a vinda aos autos, também, da alegada denúncia anônima de munícipe, que como se viu, não se sabe nem sequer se indicava usuários de drogas no local ou tráfico.

Como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, que estivesse presente no momento do flagrante, mesmo havendo relato de que se trataria de local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que o réu negou o tráfico de drogas, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência do comércio espúrio pelo acusado. Também, nem mesmo a abordagem ocorrera no caso por policiais, mas por Guardas Civis Metropolitanos, a quem não competia este tipo de atividade, tratando-se, portanto, de atuação ilegal.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações daqueles que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Por oportuno, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, a par dos depoimentos prestados, são em regra produzidos outros elementos de prova, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida gravação audiovisual dos fatos ou qualquer testemunha distinta dos guardas que pudesse corroborar a versão acusatória, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci, embora tratando de depoimento de policiais:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Voltando ao caso em questão, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelos guardas pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado o réu a propriedade ou porte da droga em juízo, e não havendo, além da declaração dos guardas civis metropolitanos, que não possuem função constitucional para tal atuação, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTE WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Frise-se, ainda, por oportuno, que sequer houve a vinda aos autos de perícia no celular do acusado, com conversas entre ele e demais pessoas que indicassem a venda de drogas.

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelo réu, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelo acusado, mormente quando se verifica que a diligência de apreensão foi realizada por agentes sem competência específica para tanto.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dúvida, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

“...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos.”

“Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo”

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carregadas aos autos



demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150 ), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva. Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Como se vê, no caso em tela, considerando o teor do interrogatório, as inconsistências apontadas e havendo apenas os testemunhos guardas civis metropolitanos, que são a reprodução das declarações que constam em inquérito, os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com segurança necessária que o acusado praticava o crime inserto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Dessa forma, remanescem dúvidas acerca do envolvimento do acusado com o crime a ele imputado, em que pese haja apreensão de certa quantidade de drogas a ele imputada. Saliente-se que do cotejo da prova oral não é possível concluir que a droga estava com o acusado.

Portanto, seja por conta da atuação ilegal da guarda civil, seja por conta das inconsistências nos depoimentos, a absolvição se impõe.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu LUIS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es)

nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, com urgência.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA